

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2279/2551

พนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี
นายมงคลหรืออ้วน ด้านเสนา

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (1), มาตรา 59, มาตรา 334

การที่จำเลยเอาเครื่องรับโทรทัศน์สี 1 เครื่อง เครื่องเสียงสเตอริโอ 1 เครื่อง ของกลางของผู้เสียหายไปจากบ้านของผู้เสียหายเพราะ ส. ซึ่งเป็นสามีของผู้เสียหาย เป็นหนี้จำเลย โดยจำเลยไม่ได้ทำให้ทรัพย์สินอย่างอื่นเสียหาย คงยกเอาทรัพย์สินของ กลางไปเท่านั้นโดยจำเลยบอกว่าถ้าอยากได้คืนให้ ส. เอาเงินไปไถ่ ซึ่งวันรุ่งขึ้นเมื่อ เจ้าพนักงานตำรวจไปที่บ้านของจำเลย ก็พบจำเลยและทรัพย์สินของกลางดังกล่าว เชื่อ ว่าจำเลยเอาทรัพย์สินของกลางไปเพื่อให้ ส. หรือผู้เสียหายไปติดต่อชำระหนี้ที่ค้างชำระ ต่อกันการกระทำของจำเลยจึงมิได้เป็นการเอาทรัพย์สินของผู้อื่นไปโดยทุจริตหรือเพื่อ แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่เป็น ความผิดฐานลักทรัพย์

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2541 เวลากลางคืนหลังเที่ยง จำเลยโดย ไม่มีเหตุอันสมควร เข้าไปในบ้านอันเป็นเคหสถานของนางกมลทิพย์ผู้เสียหายโดย ทุบประตูบ้าน ดึงกระชากประตูบ้านจนเปิดออก อันเป็นการรบกวนการครอบครอง อสังหาริมทรัพย์ของผู้เสียหายโดยปกติสุข แล้วลักเครื่องรับโทรทัศน์สี 1 เครื่อง

ราคา 13,970 บาท เครื่องเสียงสเตอริโอ 1 เครื่อง ราคา 4,000 บาท ของผู้เสียหาย
ไปโดยหลักผู้เสียหายจนล้มลง เพื่อความสะดวกแก่การลักทรัพย์ การพาทรัพย์นั้นไป
ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยและยึดเครื่องรับโทรทัศน์สี 1
เครื่อง เครื่องเสียงสเตอริโอ 1 เครื่อง เป็นของกลางซึ่งผู้เสียหายรับคืนแล้ว ขอให้
ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335, 339, 362, 364, 365, 91

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
339 วรรคสอง, 365 (3) ประกอบมาตรา 364 การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียว
เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามมาตรา 339 วรรคสอง ซึ่งเป็น
กฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 10 ปี
จำเลยให้การรับสารภาพชั้นจับกุมเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ
ลดโทษให้หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 6 ปี 8 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงยุติว่า ตามวันเวลาและสถานที่
เกิดเหตุในฟ้องจำเลยเข้าไปในบ้านของผู้เสียหายเพื่อทวงหนี้ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่
จำเลยขายให้นายสำราญสามีของนางกมลทิพย์ผู้เสียหาย แล้วจำเลยเอาเครื่องรับ
โทรทัศน์สี 1 เครื่อง เครื่องเสียงสเตอริโอ 1 เครื่องของกลางของผู้เสียหายไป มี
ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลย ว่า จำเลยกระทำความผิดตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์ภาค 1 หรือไม่ โจทก์มีผู้เสียหายเบิกความว่าในวันเกิดเหตุเวลาประมาณ 23

นาฬิกา พยานได้ยินเสียงก๊อนหินขว้างประตูบ้านเสียงเคาะประตูบ้าน แล้วจำเลยถีบประตูพังเข้ามา จำเลยกระชากแขนพยาน จำเลยพูดว่าไอ้ราษฎรหน้าตัวเมียให้ชดใช้เงิน พยานบอกจำเลยว่านายสำราญไม่อยู่ จำเลยทวงค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่นายสำราญซื้อไปจากจำเลย และยั้ค้างชำระค่าบริการ 1,100 บาท แต่ผู้เสียหายบอกว่าไม่มีเงิน จำเลยยกเครื่องรับโทรศัพท์และเครื่องเสียงสเตอริโอของกลาง ผู้เสียหายและบุตรของผู้เสียหายเข้าไปห้ามไม่ให้จำเลยเอาของกลางไป จำเลยบดมือบุตรของผู้เสียหาย และผลักผู้เสียหายจนผู้เสียหายล้มลง เห็นว่า หลังจากเกิดเหตุแล้ว ในวันรุ่งขึ้นร้อยตำรวจโทชนะชัยพนักงานสอบสวนไปตรวจที่เกิดเหตุ และถ่ายรูปประตูบ้านดังกล่าวไว้ตามภาพประกอบสำนวนการสอบสวน ซึ่งตามภาพถ่ายดังกล่าว ประตูบ้านของผู้เสียหายเปิดออกไปทางนอกบ้านและผู้เสียหายเบิกความว่าไม่สามารถดันประตูเข้าไปข้างในได้เพราะติดสนับขอบวงกบประตู ปรากฏว่าประตูดังกล่าวยังคงอยู่ในสภาพปกติ ไม่พังดังผู้เสียหายเบิกความส่วนที่ผู้เสียหายเบิกความว่า จำเลยใช้มือกระชากประตู โดยจำเลยใช้เท้ายันที่ผนังปูน ทำให้กลอนประตูจ้งออกนั้น ผู้เสียหายก็เบิกความว่าเป็นความเข้าใจของผู้เสียหายเท่านั้นประกอบกับได้ความว่าขณะเกิดเหตุผู้เสียหายอยู่ในบ้าน ส่วนจำเลยอยู่นอกบ้านมีประตูบ้านซึ่งเป็นประตูไม้ที่ปิดอยู่ ผู้เสียหายจึงมองไม่เห็นจำเลยทำอะไรบ้าง นอกจากนี้จำสืบตำรวจประยุทธ์เจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมจำเลยเป็นพยานโจทก์เบิกความว่าคืนเกิดเหตุผู้เสียหายไปแจ้งความว่าจำเลยบุกรุกเข้าไปในบ้านของผู้เสียหาย และยึดเอาเครื่องรับโทรศัพท์และเครื่องเสียงสเตอริโอของกลางไป ไม่ปรากฏว่าผู้เสียหายแจ้งข้อเท็จจริงเรื่องจำเลยพังประตูบ้านหรือกระชากประตูบ้าน และตามบันทึกการจับกุม ก็ไม่มีข้อเท็จจริงดังกล่าวเช่นกัน ส่วนที่ผู้เสียหายอ้างว่ากลอนประตูจ้งออก ทำนองว่าจำเลยดึงจนประตูเปิดออกนั้น ตามสภาพประตูดังกล่าวข้างต้นเมื่อลงกลอนแล้ว ถ้าจะดึงจนประตูเปิดออกได้กลอนประตูน่าจะหลุดออกไปจากบานประตู หรือมีร่องรอยฉีกขาดที่วงกบประตูแต่ตามภาพถ่ายกลอนประตูยังคงติดอยู่ที่บานประตู และไม่ปรากฏร่องรอยฉีกขาดที่วงกบ

ประตุ พยานโจทก์จึงมีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยถึงประตุจนเปิดออกหรือไม่ ประกอบกับผู้เสียหายรู้จักจำเลยและจำเลยก็เคยไปทวงหนี้ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่จำเลยขายให้นายสำราญสามีของผู้เสียหายหลายครั้ง ผู้เสียหายก็ยอมรับว่าสามีของผู้เสียหายมีหนี้เกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่จริง เพียงแต่ผู้เสียหายเห็นว่าจำเลยยึดโทรศัพท์เคลื่อนที่คืนไปจากนายสำราญแล้ว ผู้เสียหายไม่ต้องชำระหนี้ให้จำเลยอีก ข้อเท็จจริงมีน้ำหนักให้เชื่อว่า ในวันเกิดเหตุจำเลยไปทวงหนี้จากนายสำราญสามีของผู้เสียหายที่บ้านของผู้เสียหาย และผู้เสียหายเปิดประตูบ้านให้จำเลยเข้าไปในบ้านของผู้เสียหายดังจำเลยนำสืบ การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดฐานบุกรุก ที่ผู้เสียหายเบิกความว่า จำเลยมัดมือบุตรของผู้เสียหายและผลักผู้เสียหายจนผู้เสียหายล้มลงก่อนที่จะเอาทรัพย์สินของกลางไปนั้น คงมีแต่ผู้เสียหายเบิกความเท่านั้น บุตรของผู้เสียหายไม่ได้มาเบิกความ ทั้งผู้เสียหายยังเบิกความด้วยว่าจำเลยไม่ได้ทำให้ทรัพย์สินอย่างอื่นเสียหาย คงยกเอาทรัพย์สินของกลางไปเท่านั้นโดยจำเลยบอกว่าถ้าอยากได้คืนให้นายสำราญเอาเงินไปไถ่ ซึ่งวันรุ่งขึ้นเมื่อเจ้าพนักงานตำรวจไปที่บ้านของจำเลย ก็พบจำเลยและทรัพย์สินของกลางดังกล่าว และจำเลยตำรวจประตุเจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมจำเลยเป็นพยานโจทก์เบิกความว่า จำเลยนำของกลางไปจากบ้านของผู้เสียหายเพราะผู้เสียหายเป็นหนี้จำเลย เชื่อว่าจำเลยเอาทรัพย์สินของกลางของผู้เสียหายไปเพื่อให้นายสำราญหรือผู้เสียหายไปติดต่อชำระหนี้ที่ค้างชำระต่อกัน การกระทำของจำเลยจึงมิได้เป็นการเอาทรัพย์สินของผู้อื่นไปโดยทุจริต หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์ จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานชิงทรัพย์ด้วยที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาของจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

(พีรพล พิษยวัฒน์-ชินวิทย์ จินดา แด้มแก้ว-พิสิฐ จูติภัก)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การบังคับชำระหนี้โดยผลการของลูกหนี้ จะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์หรือไม่ แนวคำพิพากษาศาลฎีกาจะยังเห็นต่างกันอยู่ เพราะมีคำพิพากษาศาลฎีกาบางเรื่องเหมือนกันที่เห็นว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ (เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2549/2532) แม้ว่าคำพิพากษาศาลฎีกาส่วนใหญ่รวมถึงคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้จะตัดสินไปในทำนองว่าการกระทำของจำเลยไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์เพราะขาดเจตนาทุจริตก็ตาม ปัญหาในเรื่องการบังคับชำระหนี้โดยผลการของลูกหนี้ว่าจะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์หรือไม่นั้น ตามกฎหมายเยอรมันจะอยู่ในส่วนของเจตนาพิเศษโดยความผิดอาญฐานลักทรัพย์ตามกฎหมายเยอรมันนั้นนอกจากการกระทำของผู้กระทำจะต้องครบองค์ประกอบภายนอกและองค์ประกอบภายในที่ประกอบไปด้วยเจตนารรรมดาแล้ว ผู้กระทำจะต้องมีเจตนาพิเศษ กล่าวคือความตั้งใจที่จะเอาทรัพย์สินนั้นไว้เป็นของตนด้วย

(Zueignungsabsicht) และจะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ก็ต่อเมื่อเจตนาพิเศษดังกล่าว กล่าวคือความตั้งใจที่จะเอาทรัพย์สินไว้จำเป็นต้องเป็นไปโดยมิชอบด้วย

(Rechtswidrigkeit der Zueignung) ในหมายเหตุท้ายคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ผู้เขียนจึงจะจำกัดประเด็นในส่วนกฎหมายเยอรมันไว้เฉพาะความตั้งใจที่จะเอาทรัพย์สินไว้โดยมิชอบ ความมิชอบด้วยกฎหมายของความตั้งใจที่จะเอาทรัพย์สินไว้

(Rechtswidrigkeit der Zueignung) ผู้กระทำจะต้องเอาไปซึ่งทรัพย์สินโดยมีความตั้งใจที่จะเอาทรัพย์สินไว้โดยมิชอบ ความตั้งใจที่จะเอาทรัพย์สินไว้ซึ่งถือว่าเป็นองค์

ประกอบภายในของความผิดฐานลักทรัพย์นี้จะมีส่วนของความมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งถือว่าเป็นส่วนขององค์ประกอบภายนอกอยู่ด้วย ซึ่งความมิชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีนี้จะเป็นคนละกรณีกับความผิดกฎหมายที่อยู่ในส่วนโครงสร้างความผิดอาญา ข้อสอง (คือเหตุที่ทำให้การกระทำของผู้กระทำชอบด้วยกฎหมาย เช่น ป้องกัน เป็นต้น) ความมิชอบด้วยกฎหมายในที่นี้จึงหมายถึงเฉพาะกรณีที่ผู้กระทำตั้งใจจะเอาทรัพย์ไว้นั้นจะต้องเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายแต่มิใช่ความมิชอบด้วยกฎหมายของการเอาไปซึ่งทรัพย์ที่อยู่ในส่วนขององค์ประกอบภายนอกของความผิดอาญาฐานลักทรัพย์ ดังนั้น ตามกฎหมายเยอรมันในความผิดฐานลักทรัพย์จะต้องแยกความมิชอบด้วยกฎหมายในทั้งสองกรณีนี้ออกจากกัน ดังนั้น การเอาไปซึ่งทรัพย์อาจจะมิชอบด้วยกฎหมายแม้ว่าความตั้งใจที่จะเอาทรัพย์ไว้ของผู้กระทำจะชอบด้วยกฎหมายก็ตามหรือในทางกลับกันความตั้งใจที่จะเอาทรัพย์ไว้ของผู้กระทำอาจจะมิชอบด้วยกฎหมายแม้ว่าการเอาไปซึ่งทรัพย์ของผู้กระทำจะชอบด้วยกฎหมายก็ตาม ตัวอย่างที่ 1 O ได้ขายจักรยานให้ T และ T ได้จ่ายค่าจักรยานหมดแล้วแต่ O ก็ยังไม่ยอมส่งมอบจักรยานให้ T เสียที หลังจากที่ T หมดความอดทน และเดินเข้าไปร้านของ O แล้วหยิบจักรยานที่จอดเอาไว้ไป ตามตัวอย่างที่ 1 การกระทำของ T ครอบงำองค์ประกอบภายนอกของความผิดฐานลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายก็ดี การจ่ายค่าจักรยานก็ดี ไม่มีผลทำให้องค์ประกอบในส่วนของทรัพย์ "ผู้อื่น" เปลี่ยนไป เฉพาะเมื่อได้มีการส่งมอบจักรยานตามมาตรา 929 ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันแล้วเท่านั้นที่จะทำให้ความเป็นทรัพย์ "ผู้อื่น" หมดไป นอกจากนี้ T ก็ได้กระทำโดยมีเจตนาพิเศษที่จะเอาจักรยานไว้เป็นของตนเอง อย่างไรก็ตาม เจตนาพิเศษดังกล่าวนี้ (เจตนาที่จะเอาทรัพย์ไว้เป็นของตนเอง) ตามความเห็นฝ่ายข้างมากแล้วเป็นไปโดยชอบ (nichtrechtswidrig) เพราะ T มีสิทธิในจักรยานตามมาตรา 433(1) ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันและสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิที่ปราศจากข้อโต้แย้งจาก O ด้วย ดังนั้น การกระทำของ T จึงไม่ครอบงำองค์ประกอบภายในมาตรา 242

(1) ประมวลกฎหมายหมายอาญาเยอรมัน แต่อย่างไรก็ตาม T ก็ไม่มีสิทธิที่จะใช้กำลัง บังคับเอาจักรยานด้วยตนเอง การกระทำที่เป็นการเอาไปของ T จึงเป็นไปโดยมิชอบ และเป็นการใช้อำนาจบังคับด้วยตนเองซึ่งต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่ง เยอรมันมาตรา 858 (1) แต่การกระทำของ T ไม่เป็นความผิดอาญาเพราะการเอาไป ซึ่งทรัพย์สินที่ผู้กระทำมีเจตนาพิเศษที่จะเอาทรัพย์สินไว้เป็นของตนเองโดยชอบนั้นไม่ครบ องค์ประกอบภายในของความผิดฐานลักทรัพย์ ตัวอย่างที่ 2 A ขายจักรยานให้ B ใน ราคา 200 มาร์ค B ยังไม่ได้ชำระราคาค่าจักรยาน จักรยานจอดอยู่ที่บ้านของ A เมื่อ B ไปหา A ที่บ้านเพื่อที่จะรับจักรยานไป A ได้แจ้งแก่ B ว่าขอเลิกสัญญาซื้อขายกับ B และ B จะไม่ได้รับจักรยานเพราะ A จะขายจักรยานให้ C เนื่องจาก C ได้เสนอ ราคาที่จะซื้อเป็นเงิน 300 มาร์ค และ C จะมารับจักรยานไปในวันนี้ เมื่อ B ได้ฟังดัง นั้นจึงได้คว้าจักรยานและขับหนีออกไป B กระทำโดยมีเจตนาพิเศษที่จะเอาจักรยาน ไว้เป็นของตน แต่ B ไม่ได้จ่ายค่าจักรยานเพราะคิดว่าอย่างไรเสีย A ก็จะไม่รับเงิน 200 มาร์ค ของตนเพราะ A ได้บอกเลิกสัญญากับตนไปแล้ว ในตัวอย่างที่ 2 นี้ ความ ตั้งใจที่จะเอาจักรยานไว้ของ B เป็นไปโดยมิชอบแม้ว่าในขณะที่ B คว้าจักรยานไป นั้นจักรยานยังเป็นวัตถุของสัญญาซื้อขายก็ตามและ A ก็ไม่มีสิทธิที่จะเลิกสัญญาซื้อ ขายฝ่ายเดียวหลังจากที่ C เสนอที่จะซื้อจักรยานในราคาที่สูงกว่า ข้อเท็จจริงดัง กล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดสิทธิที่จะเลิกสัญญาได้ แต่อย่างไรก็ตามประมวลกฎหมายแพ่ง เยอรมันก็ไม่ได้ให้อำนาจแก่ B ที่จะสามารถใช้กำลังบังคับเอาจักรยานด้วยตนเองได้ กรณีตามตัวอย่างที่ 2 จะต่างจากตัวอย่างที่ 1 ตรงที่สิทธิเรียกร้องของ B ยังมีข้อโต้แย้งอยู่เพราะ B ยังไม่ได้ชำระราคาค่าจักรยาน เจตนาพิเศษของ B ที่จะเอาทรัพย์สินไว้ เป็นของตนจึงเป็นไปโดยมิชอบ อย่างไรก็ตาม การที่ B เอาไปซึ่งจักรยานก็เป็นไป โดยชอบเพราะตามมาตรา 229 ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน B มีสิทธิที่จะเอา จักรยานไว้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของตน (อย่างน้อยที่สุดก็ในส่วนขององค์ประกอบ ภายนอกของเหตุที่ผู้กระทำมีอำนาจกระทำได้ในกรณีนี้จึงมีอยู่ครบ) ความตั้งใจที่จะ

เอาทรัพย์สินไว้โดยมิชอบอาจหมดไปโดยเหตุที่ผู้กระทำให้อำนาจกระทำได้โดยทั่ว ๆ ไป
ก็ได้ (allgemeine Rechtfertigungsgrunde) เช่น ความจำเป็นที่ชอบด้วยกฎหมาย
(รายละเอียดดูในสิทธิ เสงวิโรจน์พัฒน์, ความจำเป็นที่ชอบด้วยกฎหมายตาม
กฎหมายอาญาเยอรมัน, ดุลพาท เล่ม 2 ปีที่ 54 พฤษภาคม - สิงหาคม 2550, หน้า
187-190) ตัวอย่าง ไฟไหม้บ้านของ E เพราะ E มีเครื่องดับเพลิงเพียงเครื่องเดียว
จึงบอกให้ T ซึ่งเป็นลูกชายเข้าไปในบ้านของ O เพื่อนข้างบ้านที่ไปเที่ยวอยู่และเอา
เครื่องดับเพลิงของ O มาดับไฟในบ้าน T เข้าไปในบ้านของ O เอาเครื่องดับเพลิง
ของ O มาดับไฟในบ้านของ E เมื่อเพลิงสงบ T ก็เอาเครื่องดับเพลิงซึ่งเป็นถังเปล่า
ไปคืนให้แก่ O ซึ่งการคืนถังเปล่าดังกล่าว T ก็รู้ดี ในส่วนของเครื่องดับเพลิงของ O
นั้น T ทำไปโดยไม่มีเจตนาพิเศษที่จะเอาไว้เป็นของตนเองเพราะเอามาคืนหลังจาก
ใช้เสร็จ แต่ในส่วนของเชื้อเพลิงที่อยู่ในถังดับเพลิงถือว่า T มีเจตนาพิเศษที่จะเอาไว้
เป็นของตน สิทธิตามสัญญาต่อ O ในการเอาเครื่องดับเพลิงมาก็ไม่มี ในกรณีที่
สันนิษฐานได้ว่า O ยอมให้เอาเครื่องดับเพลิงมาใช้ได้ก็จะเป็นกรณีของความยินยอม
ที่พึงสันนิษฐานได้ซึ่งจะยกเว้นความผิด (รายละเอียดดูใน สิทธิ เสงวิโรจน์พัฒน์,
ความยินยอมที่พึงสันนิษฐานได้ตามกฎหมายอาญาเยอรมัน, บทบัณฑิตย เล่ม 60
ตอน 4 พ.ศ.2547 หน้า 160-171) แต่แม้ว่าจะทำไปโดยขัดต่อความประสงค์ของ O
ก็ตาม T ก็สามารถใช้เครื่องดับเพลิงได้เพราะมาตรา 904 ประโยคที่หนึ่งประมวล
กฎหมายแพ่งเยอรมัน O ไม่อาจที่จะขัดขวางการใช้เครื่องดับเพลิงได้ในสถานการณ์
ที่จำเป็นของ E ในกรณีนี้ O มีหน้าที่ที่จะต้องยอมรับการละเมิดของ E ความตั้งใจที่
จะเอาน้ำยาดับเพลิงไว้จึงกระทำได้โดยชอบตามมาตรา 904 ประโยคที่หนึ่งประมวล
กฎหมายแพ่งเยอรมัน ตามทฤษฎีกฎหมายอาญาในภาคทั่วไปนั้น สัญญาตาม
กฎหมายแพ่ง (der zivilrechtliche Vertrag) ก็ถือว่าเป็นเหตุที่ทำให้ผู้กระทำให้
อำนาจกระทำได้ในส่วนของความผิดอาญาฐานลักทรัพย์ สิทธิที่จะได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์
ตามสัญญา (der vertragliche Eigentumsverschaffungsanspruch) จะเป็นผลให้

ความมิชอบด้วยกฎหมายหมดไป กล่าวคือตามความเห็นฝ่ายข้างมากเจตนาพิเศษที่จะเอาทรัพย์สินไว้ของผู้กระทำผิดนั้นจะเป็นไปโดยชอบเมื่อผู้กระทำมีสิทธิเรียกร้องให้ส่งมอบทรัพย์สิน โดยสิทธิเรียกร้องดังกล่าวสามารถบังคับได้โดยปราศจากข้อโต้แย้ง และเป็นสิทธิเรียกร้องที่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย ตัวอย่าง เจ้ามรดก W ได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้แก่ O ซึ่งเป็นลูกสาวคนเดียวโดยพินัยกรรมดังกล่าว เจ้ามรดก W ได้พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดและลงลายมือชื่อไว้ ส่วน A ซึ่งดูแลเจ้ามรดกก่อนตายเจ้ามรดก W ได้ทำพินัยกรรมไว้ในฉบับเดียวกันยกแจกันดอกไม้จากเมืองจีนให้ A แล้ว W ก็ส่งสำเนาพินัยกรรมแต่ละฉบับไปยัง O และ A หลังจากที่ W ตาย O ก็เข้ามาครอบครองบ้าน A มาเยี่ยม O ที่บ้านเพื่อแสดงความเสียใจและพูดคุยเกี่ยวกับแจกันจากเมืองจีน เมื่อ O เข้าไปในครัวเพื่อเตรียมกาแฟมาเลี้ยง A ก็แอบเอาแจกันจากเมืองจีนซ่อนไว้ในกระเป๋าทือ เมื่อดื่มกาแฟเสร็จ A ก็ลา O กลับไปพร้อมแจกันจากเมืองจีน O ไม่ได้สังเกตเห็นการลักแจกันของ A ตามมาตรา 1922 (1) ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน O ได้รับทรัพย์สินมรดกจากบิดาทั้งหมดเมื่อบิดาตาย รวมทั้งแจกันจากเมืองจีนด้วยแม้ว่าตามมาตรา 2247 (1), 125 ประโยคที่หนึ่ง ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน พินัยกรรมที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดจะไม่สมบูรณ์ตามแบบ (จะชอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน มาตรา 2247 (1) ก็ต่อเมื่อต้องเขียนด้วยลายมือทั้งฉบับและลงลายมือชื่อไว้) ก็มีผลแต่เพียงว่าพินัยกรรมนั้นไม่มีผลบังคับ มรดกก็ยังโอนไปตามหลักกฎหมายมรดกทั่วไปซึ่งทำให้ O รับมรดกแต่เพียงผู้เดียวตามมาตรา 1924, 1930 ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน เพราะว่าคำสั่งที่ระบุไว้ในพินัยกรรม (ein Vermaechtnis) ไม่มีผลบังคับ O จึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในแจกัน เฉพาะ O เท่านั้นที่มีสิทธิครอบครองในแจกัน A เอาไปซึ่งแจกันของ O และมีเจตนาพิเศษที่จะเอาไว้เป็นของตน เจตนาพิเศษดังกล่าวอาจเป็นไปโดยชอบได้ถ้า A มีสิทธิเรียกร้องที่จะให้โอนกรรมสิทธิ์ในแจกันดังกล่าว จากคำสั่งที่ระบุไว้ในพินัยกรรมก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้ที่ถูกระบุไว้ในพินัยกรรมให้ได้รับทรัพย์สินใดที่จะ

มีสิทธิเรียกร้องแก่ผู้รับมรดกให้โอนทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่ตนตามมาตรา 2147, 2174 ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน อย่างไรก็ตาม คำสั่งที่ระบุไว้ในพินัยกรรมก็ต้องทำให้เป็นไปตามแบบของพินัยกรรมที่คำสั่งดังกล่าวถูกระบุไว้ (พินัยกรรมแบบไหนต้องทำตามแบบอย่างไรหากคำสั่งที่ระบุไว้ในพินัยกรรมอันไหนมีฐานมาจากพินัยกรรมแบบใดก็ต้องทำตามแบบของพินัยกรรมแบบนั้น) เพราะว่าพินัยกรรมของ W ไม่มีผลบังคับ A จึงไม่ถือว่าเป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในคำสั่งที่ระบุไว้ในพินัยกรรมและไม่มีสิทธิที่จะได้รับแจกเงิน เจตนาพิเศษของ A ที่จะเอาแจกเงินไว้เป็นของตนเองจึงเป็นไปโดยมิชอบ ในทางตรงกันข้าม หาก W เขียนพินัยกรรมด้วยลายมือตนเองทั้งหมดและลงลายมือชื่อไว้พินัยกรรมดังกล่าวก็จะมีผลสมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน มาตรา 2247 มรดกก็จะตกไปยังบุคคลที่ถูกระบุไว้ในพินัยกรรม แต่ O ก็ยังเป็นผู้รับมรดกแต่เพียงผู้เดียวโดยมีภาระตามคำสั่งที่ระบุไว้ในพินัยกรรมที่จะต้องโอนแจกเงินให้ A และ A ก็จะเป็นผู้ที่มีสิทธิเรียกร้องให้ O โอนแจกเงินให้แก่ตนแต่สิทธิเรียกร้องดังกล่าวของ A ก็ไม่ได้ทำให้ A มีสิทธิที่จะเอาแจกเงินไป ในกรณีนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นในเรื่องของความมิชอบด้วยกฎหมายของการกระทำที่เป็นการเอาไป หากแต่เป็นความมิชอบด้วยกฎหมายของเจตนาพิเศษที่จะเอาทรัพย์สินไว้ ตามความเห็นฝ่ายข้างมากจึงเห็นว่าเจตนาพิเศษที่จะเอาทรัพย์สินไว้นั้นถือว่าเป็นไปโดยชอบ หากว่าผู้กระทำมีสิทธิเรียกร้องที่ไม่มีข้อโต้แย้งและที่สามารถบังคับได้ในการให้โอนทรัพย์สินแก่ตน เจตนาพิเศษที่จะเอาทรัพย์สินไว้ของ A ในกรณีที่พินัยกรรมมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายจึงเป็นไปโดยชอบ ความมิชอบด้วยกฎหมายของเจตนาพิเศษที่จะเอาทรัพย์สินไว้ถือว่าหมดไปหากว่าและเท่าที่สิทธิเรียกร้องที่จะได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน (der Eigentumsverschaffungsanspruch) นั้นเป็นสิทธิเรียกร้องที่จะได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ถูกลักไปหรืออีกนัยหนึ่งก็คือทรัพย์สินที่ถูกลักไปกับสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินนั้นต้องตรงกัน หากพิจารณาตามกฎหมายแพ่งจะหมายถึงทรัพย์สินที่เป็นวัตถุแห่งหนี้ที่ได้ระบุตัวทรัพย์สินไว้ (eine Stueckschuld) ในทางตรงกันข้าม หากสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นสิทธิ

เรียกร่องในทรัพย์ที่ไม่ได้ระบุตัวทรัพย์ไว้แต่ระบุแต่เพียงเป็นประเภทของทรัพย์ (eine Gattungsschuld) สิทธิเรียกร่องในทรัพย์กับทรัพย์ที่ถูกลักไปก็จะไม่ตรงกัน หากไม่ได้มีการคัดแยกทรัพย์ออกมาให้เป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งก่อนที่จะเอาทรัพย์ไป ตัวอย่าง T ได้สั่งซื้อมันฝรั่งจาก O จำนวน 50 กิโลกรัมและจ่ายค่าสินค้าล่วงหน้าไป แล้ว O ใส่มันฝรั่งในถุงกระสอบที่ลูกค้าสั่งโดยแต่ละกระสอบบรรจุมันฝรั่งน้ำหนัก 50 กิโลกรัม เมื่อ T มาที่ร้านของ O เพื่อรับสินค้าก็เห็นถุงมันฝรั่งจำนวน 10 กระสอบที่ยังไม่มีชื่อลูกค้าติดอยู่เลยหยิบไปหนึ่งกระสอบและขับรถออกไปจากร้านของ O เมื่อ O รู้เรื่องก็โกรธเพราะมันฝรั่งทั้งสิบกระสอบ O เตรียมที่จะจัดส่งให้กับ G ซึ่งเป็นเพื่อนของ O T เอาไปซึ่งมันฝรั่งของ O ความยินยอมของ O ที่จะทำให้การกระทำของ T ขาดองค์ประกอบภายนอกของความผิดฐานลักทรัพย์ไม่มีอยู่ เพราะ O ไม่ได้เตรียมมันฝรั่งกระสอบดังกล่าวไว้ให้ T จึงถือไม่ได้ว่ามีการส่งมอบมันฝรั่งกระสอบดังกล่าวให้แก่ T และ O ก็ไม่ได้เสนอที่จะส่งมอบมันฝรั่งกระสอบดังกล่าวให้กับ T (มาตรา 929 ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน) อย่างไรก็ตาม เจตนาพิเศษที่จะเอาทรัพย์ไว้ของ T อาจจะกระทำโดยชอบหากว่าสัญญาซื้อขายระหว่าง T และ O ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร่องในมันฝรั่งกระสอบดังกล่าวแต่เพราะทรัพย์ที่เป็นวัตถุแห่งหนี้ตามสัญญาซื้อขายเป็นแต่เพียงทรัพย์ที่ระบุไว้เป็นประเภทและไม่ได้มีการคัดแยกออกมาต่างหากซึ่งจะถือว่าเป็นกรณีที่คัดแยกออกมาต่างหากและทำให้กลายเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งก็ต่อเมื่อ O ได้เตรียมคัดแยกมันฝรั่งออกมาให้ T และติดชื่อของ T ไว้เพื่อเตรียมที่จะส่งมอบให้กับ T ความเห็นฝ่ายข้างมากเห็นว่าในกรณีของสิทธิเรียกร่องในทรัพย์ที่ระบุไว้แต่เพียงเป็นประเภทนี้ (den Gattungsanspruch) หากผู้กระทำมีเจตนาพิเศษที่จะเอาทรัพย์ไว้เป็นของตนเองถือว่าเป็นไปโดยมิชอบเพราะผู้กระทำผิดที่เป็นผู้ซื้อจะมีแต่เพียงสิทธิที่จะได้ทรัพย์ในระดับปานกลางแต่ไม่มีสิทธิในทรัพย์ชิ้นใดชิ้นหนึ่ง โดยเป็นสิทธิของผู้ขายที่จะเลือกส่งมอบทรัพย์ในระดับปานกลางจากทรัพย์ทั้งหมดที่มีอยู่ให้กับผู้ซื้อการที่ผู้ซื้อไปเอาทรัพย์มาโดยพลการจึง

เป็นการละเมิดต่อสิทธิที่จะเลือกส่งมอบทรัพย์สินของผู้ขาย เจตนาพิเศษที่จะเอาทรัพย์สิน
ไว้ของผู้กระทำผิดจึงเป็นไปโดยมิชอบ ในทำนองเดียวกับการเอาไปซึ่งทรัพย์สินที่ระบุ
ไว้แต่เพียงเป็นประเภท มีปัญหาว่าการเอาเงินไปจะถือว่าผู้กระทำมีเจตนาพิเศษที่จะ
เอาเงินไว้โดยมิชอบหรือไม่ หากว่าผู้กระทำมีสิทธิที่จะได้รับการชำระเงินจากเจ้าของ
กรรมสิทธิ์เงิน ตัวอย่าง T มีสิทธิเรียกร้องที่จะให้ O ชำระเงินคืนตามสัญญากู้ที่ถึง
กำหนดชำระแล้วจำนวน 1,000 มาร์ค วันหนึ่ง T เจอ O โดยบังเอิญที่ตู้ A.T.M.
ขณะที่ O กำลังหยิบธนบัตรฉบับละ 1,000 มาร์ค จากตู้ A.T.M. ใส่กระเป๋าเงิน T ก็
คิดว่าธนบัตรฉบับดังกล่าวจากมือของ O วิ่งหนีไป กรณีตามตัวอย่าง ศาลฎีกาเยอรมัน
เห็นว่าสิทธิเรียกร้องของ T ที่จะให้ O ชำระเงินคืนเป็นสิทธิเรียกร้องในตัวจำนวน
เงิน ไม่ใช่ในตัวเหรียญใดเหรียญหนึ่งหรือธนบัตรฉบับใดฉบับหนึ่ง ดังนั้น T จึงไม่มี
สิทธิเรียกร้องในธนบัตรฉบับละ 1,000 มาร์ค ที่คว้าไปจากมือของ O ในกรณีนี้ T มี
เจตนาพิเศษที่จะเอาทรัพย์สินไว้เป็นของตนโดยไม่มีสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินดังกล่าว
ส่วนความเห็นทางดำรัสส่วนใหญ่เห็นว่าสิทธิเรียกร้องในเงิน ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่
ธนบัตรฉบับใดฉบับหนึ่งแต่อยู่ที่จำนวนค่าของเงินว่ามีเท่าไร ไม่เฉพาะเจ้าหนี้แต่รวม
ถึงลูกหนี้ด้วยที่โดยหลักการแล้วจะชำระหนี้หรือรับชำระหนี้เป็นเหรียญหรือธนบัตร
ฉบับใดก็ได้ ความสำคัญจึงอยู่เฉพาะที่จำนวนเงินเท่านั้น ดังนั้น ในกรณีที่เป็นหนี้เงิน
ความมิชอบด้วยกฎหมายของเจตนาพิเศษที่จะเอาเงินไว้เป็นของตนนั้นจึงพิจารณา
แต่เพียงว่าผู้กระทำมีสิทธิเรียกร้องให้ชำระเงินหรือไม่โดยจำนวนเงินตามสิทธิเรียก
ร้องดังกล่าวจะต้องมีมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนเงินที่ผู้กระทำลักเอาไป นอกจากนี้
Mitsch ยังเห็นต่อไปอีกว่า ผู้กระทำจะต้องกระทำโดยมีเจตนาที่จะถือว่าการลักเอา
เงินไปดังกล่าวเป็นการชำระหนี้ให้แก่ตนและหนี้จะดับสิ้นไป จะถือว่าเป็นความผิด
ฐานลักทรัพย์ก็ต่อเมื่อผู้กระทำยังจะไปเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ให้แก่ตนอีกแม้ว่า
ตนเองจะได้ลักเอาเงินเขาไปแล้วก็ตาม ในทางตรงกันข้ามไม่ถือว่าเป็นความผิดฐาน
ลักทรัพย์เมื่อผู้กระทำที่ได้กระทำไปแล้วแรกโดยมีเจตนาพิเศษที่จะถือว่าการเอาเงิน

ไปดังกล่าวเป็นการชำระหนี้ให้แก่ตน แต่ภายหลังเปลี่ยนใจที่จะไปเรียกร้องเงินจาก ลูกหนี้อีกเพราะเห็นว่าลูกหนี้ไม่รู้ว่าตนลักเงินไป การเปลี่ยนใจในภายหลังดังกล่าว อาจเป็นความผิดสำเร็จฐานฉ้อโกงหรือพยายามฉ้อโกงก็ได้ สิทธิเรียกร้องที่จะทำให้ เจตนาพิเศษที่จะเอาทรัพย์สินไว้โดยมิชอบหมดไปต้องเป็นสิทธิเรียกร้องที่ปราศจากข้อ โต้แย้งด้วย ดังนั้น หากในขณะที่มีการเอาไปซึ่งทรัพย์สินนั้นสิทธิเรียกร้องดังกล่าวยังมี ข้อโต้แย้งอยู่หรือผู้กระทำความผิดหมายได้ว่าเมื่อตนใช้สิทธิเรียกร้องในอนาคตแล้วข้อโต้ เียงจะมีขึ้น ก็ถือว่าสิทธิเรียกร้องดังกล่าวไม่ได้ทำให้ความมิชอบด้วยกฎหมายของ เจตนาพิเศษที่จะเอาทรัพย์สินไว้หมดไป ตัวอย่าง T มีสิทธิเรียกร้องให้ O ชำระเงินให้ แก่ตน 100 มาร์ค สิทธิเรียกร้องดังกล่าวจะขาดอายุความในวันที่ 31 ธันวาคม ใน งานปาร์ตี้ฉลองปีใหม่มาก่อนที่จะขึ้นปีใหม่ 5 นาที T ได้หยิบเอาธนบัตรฉบับละ 100 มาร์คไปจาก O หนึ่งฉบับ T มีเจตนาที่จะตกลงกับ O ในวันรุ่งขึ้นว่าให้ถือว่าหนี้ ระหว่างเขาทั้งสองคนระงับสิ้นไปในขณะที่ T เอาเงิน O ไปนั้น O ไม่อยู่ในสถานะที่ จะสามารถแสดงเจตนาให้สมบูรณ์ตามกฎหมายได้เนื่องจากเมาสุราอย่างหนัก (มาตรา 105 (2) ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน) ถือว่าผู้กระทำความผิดโดยมีเจตนา พิเศษที่จะเอาทรัพย์สินไว้โดยมิชอบ หากว่าผู้กระทำเอาไปซึ่งทรัพย์สินเพื่อที่สิทธิเรียกร้อง ของตนเองจะได้ไม่ขาดอายุความและตนเองก็มองไม่เห็นโอกาสที่จะสามารถบังคับ สิทธิเรียกร้องของตนให้เป็นไปตามกฎหมายได้ ตามตัวอย่างจึงต้องถือว่า T มีเจตนา พิเศษที่จะเอาทรัพย์สินไว้โดยมิชอบแม้ว่าในขณะที่ T เอาไปซึ่งทรัพย์สินนั้นสิทธิเรียกร้อง ของ T จะไม่มีข้อโต้แย้งก็ตาม (vgl. Mitsch, Strafrecht Besonderer Teil 2, 1998, บทที่ 1, หัวข้อ 146 ff.) การที่เจ้าหนี้บังคับชำระหนี้โดยพลการ ตามกฎหมาย เยอรมันคงพอจะวางหลักได้ว่าหนี้ที่เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องให้ชำระนั้นเป็นหนี้ที่ทรัพย์สิน ซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงหรือไม่ หากใช่และสิทธิเรียกร้อง ดังกล่าวของเจ้าหนี้ปราศจากข้อโต้แย้งแล้ว แม้เจ้าหนี้จะบังคับชำระหนี้โดยพลการก็ ถือว่าขาดเจตนาพิเศษที่จะเอาทรัพย์สินไว้เป็นของตนโดยมิชอบ อย่างไรก็ตาม หาก

ทรัพย์สินที่เป็นวัตถุแห่งหนี้ไม่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจง การบังคับชำระหนี้โดย
ผลการของเจ้าหนี้ถือว่าเป็นการละเมิดต่อสิทธิที่จะเลือกชำระหนี้ของลูกหนี้และถือว่า
เจ้าหนี้มีเจตนาพิเศษที่จะเอาทรัพย์สินไว้เป็นของตนโดยมิชอบ กรณีที่เป็นหนี้เงินศาล
ฎีกาเยอรมันจะใช้หลักในทำนองเดียวกับทรัพย์สินที่เป็นวัตถุแห่งหนี้ที่ไม่ได้กำหนดไว้
โดยเฉพาะเจาะจง ในขณะที่ความเห็นในทางตำราจะพิจารณาว่าเงินที่ผู้กระทำเอาไป
นั้นเกินกว่าสิทธิเรียกร้องที่เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องหรือไม่ หากไม่เกินก็ถือว่าจำเลย
ขาดเจตนาพิเศษที่จะเอาทรัพย์สินไว้เป็นของตนโดยมิชอบ หากนำหลักกฎหมายเยอรมัน
มาใช้ในการวางหลักเจตนาโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยก็ต้อง
ถือว่าจำเลยในคดีนี้มีเจตนาทุจริตเพราะหนี้ที่นาย ส. เป็นหนี้จำเลยเป็นหนี้เงินไม่ใช่
หนี้ในตัวทรัพย์สินของกลางที่จำเลยหยิบเอาไป (ในคดีที่หมายเหตุนี้จำเลยจะขาดเจตนา
ทุจริตก็ต่อเมื่อจำเลยเอาเงินของนาย ส. ไปและในจำนวนที่ไม่เกินกว่าที่นาย ส. เป็น
หนี้จำเลย) เมื่อจำเลยเอาทรัพย์สินของกลางไปโดยรู้และต้องการจะเอาทรัพย์สินนั้นไว้เป็น
ของตนโดยมิชอบ การกระทำของจำเลยจึงครบทั้งองค์ประกอบภายนอกและภายใน
ในความผิดฐานลักทรัพย์ สุจริต ส. แสงวิโรจน์พัฒน์